

1500024-62.2021.8.26.0698

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Comarca: Pirangi

Foro: Foro de Pirangi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... abandonada, usada para a prática do tráfico. A testemunha Júlio César Tofoli, também policial militar, disse que na rua Rio de Janeiro, na altura do numeral 90, o réu foi encontrado. O réu viu a viatura e dispensou uma sacola e correu. O réu foi abordado. Ele desferiu socos e chutes. Foi empregada força para conter o réu. Na sacola havia cocaína, crack e maconha. Não se lembra se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirangi

Vara Única

Travessa Vereador Rafael João Giglio, s/nº, Centro - CEP 15820-000, Fone: (17)

3386-2365, Pirangi-SP - E-mail: pirangi@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Reclamação:

1500024-62.2021.8.26.0698 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

FABRICIO DOS SANTOS BALBINO, CPF 153.339.244-73

Data da audiência:

03/02/2022 às 16:30h

Aos 03 de fevereiro de 2022, às 16:30 horas, por meio da plataforma Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO, comigo, Oficial Maior de seu cargo ao final nomeado e assinado, foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, Dra. Heloisa Tavares, DD. Promotora de Justiça. Presente ainda, o acusado Fabricio dos Santos Balbino acompanhado de seu advogado Dr. Robson Fernando Porto Mecha, bem como a testemunha de acusação Anderson Desidério do Carmo Massarelli e Júlio César Tofoli Junior. Presentes também as testemunhas de defesa, Leidiane da Silva Santos e Gerlandy dos Santos Marques. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se à oitiva das testemunhas presente. Após, houve o interrogatório do acusado. Em seguida, manifestou-se a Representante do Ministério Público e o Advogado de defesa. Consigna-se que, diante da vigência do Sistema de Trabalho Remoto, em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM 2545/2020), seguindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e Comunicado n. 284/2020, utilizando-se o aplicativo Microsoft Teams. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. O arquivo digital será armazenado diretamente no sistema SAJ (excepcionalmente, em caso de indisponibilidade do sistema, poderão ser armazenados junto ao OneDrive, conforme determinado no Comunicado CG nº 277/2020, disponibilizados às partes através de link de acesso a ser oportunamente liberado nos autos). Na sequência, pelo MM. Juiz de Direito foi dito: Proferida a r. Sentença em audiência: "Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO. Vistos. FABRICIO DOS SANTOS BALBINO foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigos 129, §12, e 329, caput, ambos do Código

Penal, tudo em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal). A exordial acusatória narrou que: “no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta de 11h00, na Rua Rio de Janeiro, 90, Cidade de Vista Alegre do Alto, Comarca de Pirangi, FABRICIO DOS SANTOS BALBINO, qualificado à fl. 29 (então com 18 anos de idade), trazia consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 15 (quinze) papelotes de 'Cannabis sativa L.', substância popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 37,8g (trinta e sete gramas e oito decigramas), 40 (quarenta) supositórios contendo cocaína, pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas), e 46 (quarenta e seis) pedras de cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 7,4g (sete gramas e quatro decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 42/45 e laudo químico-toxicológico de fls. 173/175. Consta, também, que, nas condições de tempo e local supracitadas, FABRICIO DOS SANTOS BALBINO, qualificado à fl. 29, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias FABRICIO DOS SANTOS BALBINO, qualificado à fl. 29, ofendeu a integridade corporal de Anderson Desiderio do Carmo Massarelli e Júlio César Tofoli, policiais militares no exercício da função, causando as lesões corporais descritas nos laudos de fls. 167/168 e 169/170” (fl. 185). Determinada a notificação do réu (fl. 196), o que foi efetivado (fl. 240). A Defesa apresentou defesa prévia às fls. 225/229. Ante a não constatação de qualquer hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2021, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus e, ainda, designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 241/242). Citação formalizada à fl. 265. Impetrado o Habeas Corpus, foi concedida “a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, nos Autos n. 1500024-62.2021.8.26.0698, da Vara Única da comarca de Pirangi/SP, pelas medidas cautelares do art. 319, II, IV e V, do CPP, que deverão ser implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular competente” (fl. 219). Em audiência, as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu interrogado, e foi declarado o encerramento da fase instrutória. A Douta Promotoria de Justiça apresentou memoriais orais, pugnando pelo acolhimento parcial da denúncia, com absolvição em relação ao crime de lesão. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição por ausência de provas, a fixação de penas mínimas, aplicação da atenuante da menoridade relativa e a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n.11.343, de 2006. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito tramitou regularmente, não há vícios ou nulidades que impossibilitem o julgamento do processo, razão pela qual passo à análise da questão de fundo. No mérito, a pretensão punitiva é de se acolher. A testemunha Anderson Desiderio do Carmo Massarelli, policial militar, disse que estava em patrulhamento e tinha informações de que o réu era traficante. O réu viu a viatura e soltou uma sacola. O réu investiu contra os policiais e tentou escapar da ação policial. Houve ferimentos e na sacola foram encontradas drogas em uma casa abandonada, usada para a prática do tráfico. A testemunha Júlio César Tofoli, também policial militar, disse que na rua Rio de Janeiro, na altura do numeral 90, o réu foi encontrado. O réu viu a viatura e dispensou uma sacola e correu. O réu foi abordado. Ele desferiu socos e chutes. Foi empregada força para conter o réu. Na sacola havia cocaína, crack e maconha. Não se lembra se havia outras pessoas no local. Lembra que havia “populares na rua”. Havia denúncia acerca da prática do tráfico por parte do réu. A testemunha Gerlandy dos Santos Marques disse que foi ao mercado e voltou e viu que o réu estava na casa ao lado, rua Rio de Janeiro, n. 90. A vizinha da frente chamou a depoente e disse que a polícia estava prendendo o réu. Indagou a razão da prisão e viu que os policiais bateram muito nele. O réu estava parado e depois começou a se defender. O réu mordeu o policial e foi em razão disso que o policial parou de enforçar. O réu trabalhava na roça. Não viu a sacola e nem as drogas. Sabe que o réu é usuário. A testemunha Leidiane da Silva Santos disse que viu os policiais prendendo o réu na rua Rio de Janeiro. O réu é uma boa pessoa e estava trabalhando e casado. Quando viu o réu não estava algemado. O réu não estava deixando algemar ele. Não viu a abordagem e nem a sacola. Rua Rio de Janeiro, n. 90, sempre morou gente lá. Interrogado, o réu negou as acusações. A materialidade

restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 42/45, laudo químico-toxicológico de fls. 173/175 e laudos de fls. 167/168 e 169/170. A autoria também é inconcussa. A prova oral, especialmente aquela colhida em razão do depoimento prestados pelos Policiais Militares, deixou claro que o réu trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tal como prevê o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343, de 2006. E é em razão de tal conduta que se apanha a licitude da ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao efetivar o flagrante eis que "o crime de tráfico de drogas (...) constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal" (STJ, HC 324.844/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.06.2016). O artigo 33, caput, da Lei de Drogas é crime de ação múltipla. São vários os verbos abarcados pelo tipo e dentre eles está o "trazer consigo", o que abarca a conduta do agente que se vale de bolsa, mochila, sacola, ou qualquer outro recipiente. É justamente essa a hipótese, em que o réu se utilizou de uma sacola para carregar a droga. Assim, foram apreendidos 15 (quinze) papelotes de maconha, com peso líquido de 37,8g (trinta e sete gramas e oito decigramas), 40 (quarenta) supositórios contendo cocaína, pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas), e 46 (quarenta e seis) pedras de cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 7,4g (sete gramas e quatro decigramas), quantidade e variedade essas totalmente incompatíveis com a condição de usuário. Então, não há como se reconhecer que o entorpecente apreendido destinava-se a uso próprio, tal como prevê o artigo 28 da Lei de Drogas. E o fato do réu não ter sido flagrado comercializando o entorpecente, não desvia a aplicabilidade do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pois a mera conduta de trazer consigo a substância, no contexto anteriormente descrito, implica a prática tipificada pelo dispositivo supra. Pontuo que não há sequer indícios que apontem para intenção de incriminação gratuita por parte dos agentes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos" (STJ - AgRg no HC: 542882 SP 2019/0325854-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020). E mais, a figura do usuário pode coexistir com a do traficante. Uma não exclui a outra e quando elas se fundem, há preponderância da figura do traficante. Isto é, "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última,

de maior gravidade." (TJSP, HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498). Por fim, é de aplicar o §4º do artigo 33, eis que o réu cumpre os requisitos lá estabelecidos, vale dizer, trata-se de agente primário, de bons antecedentes e não há indicação de que integra organização criminosa, ou mesmo se dedique às atividades criminosas, não se extraindo tais elementos da prova oral colhida em juízo. No que se refere à fração, a quantidade de drogas e variedade delas não podem ser desconsideradas, motivo pelo qual a fração de 1/6 se mostra justa e proporcional. Com relação ao delito tipificado pelo artigo 329, do Código Penal, também restou devidamente demonstrado. A situação fática se faz clara e, como narrado tanto pelos policiais militares, o réu tentou se furtar à ação policial e investiu contra aqueles que efetuavam a sua prisão em flagrante contra os policiais Anderson Desiderio do Carmo Massarelli e Júlio César Tofoli, fazendo com que eles se ferissem. Assim, o réu com vontade e consciência agiu com indisfarçada pretensão de se opor à execução de ato legal, mediante violência, incidiu, no tipo previsto no artigo 329 do Código Penal. A testemunha Gerlandy dos Santos Marques apontou que foram os policiais que investiram contra o réu, mas a testemunha Leidiane da Silva Santos, que também viu a ação, não trouxe o mesmo relato, motivo pelo qual não há como se fazer um juízo de certa acerca daquilo que foi dito no primeiro relato. E não foi só. A conduta do réu, para além de implicar na tipificação do artigo 329, também acabou por se enquadrar no 129, §12, tudo do

Código Penal eis que os laudos periciais de fls. 167/168 e 169/170 foram expressos ao apontar que a conduta da parte ré efetivamente reverberou na integridade física dos policiais, causando neles "FERIMENTO EM ANTEBRAÇO DIREITO, FERIMENTO EM DORSO MÃO ESQUERDA, FERIMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO DEDO MÃO DIREITA, ESCORIAÇÕES EM COTOVELO DIREITO" (fl. 168) e "VERGÃO EDEMAÇEADO E AVERMELHADO EM PESCOÇO E REGIÃO RETROAURICULAR ESQUERDA, ESCORIAÇÃO EM COTOVELO DIREITO, FERIMENTO EM DOIS DEDOS DA MÃO DIREITA, HIPEREMIA EM ANTEBRAÇO ESQUERDO" (fl. 170). Logo, há duas condutas típicas, ambas com enquadramento nos termos do artigo 129, §12º, do Código Penal, com aplicação da fração de 1/6. E nem se diga da consunção eis que a pena do crime de resistência se aplica sem prejuízo daquelas correspondentes à violência. A propósito: "Nem mesmo cabe a absorção do crime de resistência pelo de lesão corporal, eis que o artigo 329, § 2º do Código Penal é claro ao dispor que as penas previstas no dispositivo serão aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência, o que reforça a conclusão de que se trata de delitos autônomos, com objetividade jurídica diversa" (TJSP; Apelação Criminal 0007904-82.2018.8.26.0635; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021). O caso é, pois, de imputação de responsabilidade penal eis que presentes os fatos típicos, ilícitos e culpáveis. Passo a dosar as penas. No que toca ao crime de tráfico, na primeira fase, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que estão em número favorável ao acusado, devendo a quantidade de drogas reverberar na terceira fase da dosimetria de pena, sob pena de bis in idem. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, há atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, mas que, em razão da pena já estar no mínimo legal, aqui, não produz efeito. Não há agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, há uma causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, fração mínima em razão da quantidade e variedade de drogas, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sem prejuízo do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Não existe causa de aumento de pena. Já no que se refere ao crime do artigo 329, do Código Penal, na primeira fase, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, não há qualquer circunstância para ser relevada em desfavor do réu. Portanto, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, pois ainda que o réu seja menor e 21 anos, nesta fase da dosimetria a pena base não deve ficar aquém do mínimo legal, por isso deixo de considerar a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, mantenho a pena em 02 (dois) meses de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Sendo assim, torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) meses de detenção. Relativamente aos crimes de lesão corporal, as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, são neutras ou favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena acima do no mínimo legal em 03 (três) meses de detenção para cada um dos dois crimes eis que incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Não há agravante. Há atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, mas que, em razão da pena já estar dosada em seu patamar mínimo, não produz efeitos. Inexistem causas de diminuição. Presente a causa especial de aumento prevista no artigo 129, §12, do Código Penal, isto é, lesão for praticada contra policial militar no exercício da função, aumentos ou em decorrência dela, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias para cada um dos dois crimes eis que incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. No que toca ao concurso de crimes, apesar dos crimes terem sido cometidos numa mesma oportunidade, fica clara que houve mais de uma conduta com a produção de resultados diversos, motivo pelo qual o caso é de concurso material, isto é, mais de uma ação que implicou em mais de um crime. Assim, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sem prejuízo do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, e 09 (nove) meses de detenção. Deverá ser

executada em primeiro lugar a pena de reclusão, nos termos do § 2º, do artigo 69, do CP. O regime de cumprimento de pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, é o semiaberto. A substituição por pena restritiva de direitos não é adequada em razão da natureza dos crimes ou mesmo em razões das circunstâncias em que foram praticados. Resta também impossível também, pelos mesmos motivos, a suspensão condicional da pena compreendida no artigo 77, do Código Penal. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para condenar o réu F.S.B. a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sem prejuízo do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa no valor mínimo, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, e ainda 09 (nove) meses de detenção em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 129, §12 (duas vezes), e 329, caput, ambos do Código Penal, tudo em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), em regime inicial semiaberto. Ficam mantidas as mesmas cautelares já fixadas pela Instância Superior quando da concessão da ordem de habeas corpus. Transitada em julgado a sentença: Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados. Notifique-se o (a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP; Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84; Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD); Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88; Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado. Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça. Sentença proferida em audiência. Já saem os presentes intimados." ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Everaldo Rogério da Silva, digitei.